



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

**מס' תיק: 5/587/2016
מס' בקשה: 5/602/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

המבקשים:
1. רותם ענבר
2. עו"ד אילן רצאבי ענבר
ע"י ב"כ עוה"ד אילן רצאבי ענבר
מרחוב בלוח 2 תל אביב

- נ ג ד -

המשיבים:
1. אלכס קוצ'וק
2. שרית קירלי
ע"י ב"כ עוה"ד אמיר ארבל
מרחוב דיזינגוף 50 תל אביב

ה ח ל ט ה

1. המבקשים עותרים בבקשה דנן למתן סעד זמני אשר יקבע כי בידם זכות קונסטרוקטיבית לקבלת היתר בניה, ללא צורך בהסכמת המשיבים, וזאת לאור תחולת הוראות סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 וכן כי תינתן זכות גישה לקיר ביתם הגובל בקיר בית המשיבים לשם ביצוע עבודות דחופות נדרשות בדירתם.
2. המשיבים טענו בתמצית כי הבקשה הוגשה בשיהוי ובחוסר תום לב מתוך מטרה להפעיל לחץ פסול על המשיבים, וממילא אין הצדקה בדין למתן הסעדים הזמניים המבוקשים – המשיבים לא סרבו לחתום על תוכניות שעה שאלו כלל לא הוצגו להם. המשיבים גם לא התנגדו לאפשר גישה לביצוע עבודות נטענות אך התנו זאת בתנאים מינימליים לשם שמירה על קניינם.
3. ביום 06.09.16 נערך דיון בבקשה בסיומו הגיעו הצדדים להסכמה לפיה יעבירו המבקשים למשיבים את התוכניות אותם הם מבקשים לאשר במסגרת הבקשה להיתר והצדדים יבואו בניהם בדברים.
4. ביום 19.09.16 הודיעו המשיבים כי לא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות שעה שאין מבוקש לבצע הרחבה דומה.
5. אף שנותרה עוד על הפרק הצעת פשרה שהעלו המשיבים, והועברה בהתאם להחלטתי לתגובת המבקשים, מצאתי לנכון ליתן החלטה בבקשה.
6. בבואו להחליט בדבר מתן סעד זמני, יפעיל בית המשפט את המבחנים הבאים:

א. קיום ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התביעה: בשלב זה על המבקש להוכיח כי התביעה אינה טרדנית וכי קיימת שאלה רצינית שיש לדון בה (תקנה 362(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות")).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/587/2016
מס' בקשה: 5/602/2016

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

ב. **שמירה על המצב הקיים:** מתן הסעד הזמני הכרחי כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה.

ג. **מאזן הנוחות:** ביצוע הערכה של זכויות ושל תוצאות אפשריות לגבי שני הצדדים, של מתן או סירוב נתינתו של הצו הזמני. מבחן זה בודק את הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד התובע אם לא יינתן הצו, לעומת הקשיים הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד הנתבע אם הצו יוענק לתובע.

ד. **שיקולים שביושר.** (ראו אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית, עמ' 502-503).

7. בין המבחנים האמורים מתקיים יחס מקביל כך שככל שבית המשפט יתרשם כי סיכויי המבקש לזכות בתביעתו גבוהים, תפחת הדרישה בדבר מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' אחד, פ"ד נו(1) 529; רע"א 10066/04 נ.ד. ספאנטק תעשיות בע"מ נ' פ.ס.ט. ספיר אנטרפרייז בע"מ, פ"ד נט(4) 700). עם זאת, על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים בנפרד, שאם לא כן, לא ינתן הסעד הזמני (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ [פורסם באתר נבו]).

8. בנסיבות דנן עסקינן, כאמור, בבקשה למתן סעד זמני מסוג צו עשה. ההלכה קובעת כי צו כזה לא יינתן אלא במקרים יוצאי דופן: "קבלת סעד זמני מסוג צו-עשה זמני קשה יותר להשגה מאשר קבלת הסעד ההפוך (של צו מניעה זמני). בעוד שהסעד האחרון עומד בקריטריונים לעניין שמירת המצב הקיים, הרי שבמתן צו עשה זמני, יש, לכאורה, משום שינוי במצב הקיים" (אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, (מהדורה תשיעית) בעמ' 527).

בבש"א (מחוזי-ת"א) 20818/03 מלכה שלמה נ' אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ, [פורסם בנבו], נקבע: "על אף שבית המשפט מוסמך לתת צו עשה זמני (ר' הגדרת "סעד זמני) בתקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984) יימנע בית המשפט בדרך כלל מנתינתו. צו כזה יינתן רק במקרים יוצאים מן הכלל, כאשר הנזק לתובע הוא בלתי הפיך ושום פיצוי כספי לא יוכל לתקנו...".

ברע"א 5843/05 איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה נ' שרון דן השקעות בע"מ [פורסם בנבו], נקבע: "הלכה היא, כי על בית המשפט לנקוט משנה זהירות טרם שיצווה על צו עשה זמני המשנה את המצב הקיים, עוד לפני שניתנה ההכרעה הסופית בתובענה. צו עשה זמני המשנה מצב קיים ראוי שיינתן במקרים חריגים, אך כאשר נוכח בית המשפט כי התערבותו הינה חיונית בכדי למנוע תוצאה קשה ביותר וכאשר הנזק שעלול להיגרם אינו ניתן לתיקון באמצעות פיצוי כספי הולם (ע"א 213/64 ברא"ז נ' נציב המים, פ"ד יח(3) 647, 653 - 654; וכן ראו רע"א 1868/98 סייג נ' המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי [פורסם בנבו]).".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/587/2016
מס' בקשה: 5/602/2016

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

9. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים, ולאור הוראות התקנות והפסיקה כאמור, אני מוצא לנכון לדחות את הבקשה.

10. ראשית, בכל הקשור לסעד הזמני המבוקש בנוגע לתחולת סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין ("הרחבה דומה") הרי שמבוקש, למעשה, מתן הסעד הסופי הנדרש בהליך, כבר במסגרת הסעד הזמני ובנסיבות דנן אין להיעתר לכך - הקביעה כי המשיבים ביצעו "הרחבה דומה" הינה, בין היתר, נגזרת של בחינה עובדתית נדרשת של הבניה אשר מבוקש לאשר בדירת המבקשים אל מול הבניה אשר בוצעה לכאורה בדירת המשיבים - לא ניתן בשלב מקדמי זה לקבוע מסמרות בנוגע לאמור, ודאי כאשר במסגרת הדיון בבקשה כלל לא הוצגה הבקשה להיתר בניה אשר מבקשים התובעים לאשר במסגרת ההליך. למעשה, גם לא הוצגה ראשית ראיה מספיקה בנוגע לבניה שבוצעה או אושרה בדירת המשיבים - לא היתר בניה ולא חוות דעת מומחה. כל שצורפו הם חלקים ממדידות לא חתומות, לא מתוארכות וגם לא ברורות - ההסברים לאמור בתשריטים הינם של המבקשים ולא של המודד.

11. זאת ועוד. היענות לבקשה משמעה, לכאורה (כנטען בבקשה), כי בידי התובעים יהיה, כבר עתה, לקבל היתר בניה תכנוני לבניה שבוצעה בדירתם, וזאת בטרם הוכרעה התובענה לגופה. הנזק הצפוי בשל מתן הסעד הסופי האמור, כבר בשלב המקדמי, גדול עשרות מונים על פי הנזקים הצפויים למבקשים אם יוכרע הסעד המבוקש, על פי כללי הדין, לאחר ניהול המסכת המשפטית הקבועה בדין - קבלת היתר בניה ביד המבקשים הינה פעולה בלתי ניתנת לביטול אשר תייתר את הצורך בדיון בתובענה לגופה, תוך פגיעה אפשרית בקניין המשיבים וזאת בטרם נדון ההליך והוכרע לגופו.

12. בהקשר זה נכון יהיה להאיר כי טענת המבקשים מתבססת על כך שאין בידם למכור את דירתם וכי נגרמים להם נזקים ללא קבלת היתר בניה, בין היתר, חשיפתם לאישום פלילי (עמוד 1 לפרוטוקול שורה 16 ועמוד 2 שורות 21-24). דא עקא, אין לתובעים לבוא בהקשר זה בטענות אלא לעצמם - לאור הנטען בבקשה ומטיעוני המבקש בדיון עולה כי הבקשה למתן היתר שהוגשה מטרתה הכשרת בניה שכבר בוצעה על ידי המבקשים בעבר. אין כל הצדקה מדוע יקבלו המבקשים את הסעד הסופי המבוקש על ידם, כבר במסגרת מקדמית של ניהול ההליך, כאשר היסוד לבקשתם הינו בלתי חוקית שביצעו ללא קבלת היתר תכנוני, וממילא ללא זכות קניינית לכאורה בהעדר הסכמה פוזיטיבית של המשיבים, שהרי לשם כך הוגשה התובענה דנן.

13. למעלה מן הצורך יוער כי מטיעוני המבקשים עולה כי נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית לשם נקיטת ההליכים התכנוניים על פי דרישת הרשויות (ר' סעיף 53 לבקשה). במסגרת הבקשה לא הוכחה קיומה של הסכמת בעלי דירות אחרים בבית, שלא נתבעו בהליך, ודאי לאור טענות המשיבים בהקשר זה (ר' למשל סעיף ה למבוא, סעיף 11 וסעיף 42 לתגובה). בהתאם, גם אם ינתן הסעד הזמני המבוקש כנגד המשיבים בלבד, הרי שלכאורה כלל לא יהיה בו לסייע ביד המבקשים, על פי גרסתם (עמוד 1 לפרוטוקול שורה 20 עד עמוד 2 שורה 2).

14. שנית, על פני הדברים הבקשה הוגשה בשיהוי, ואף ניכר - הבניה המדוברת בדירת המבקשים בוצעה בשנת 2012 כאשר הבניה בדירת המשיבים בוצעה עוד קודם. לכאורה,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

**מס' תיק: 5/587/2016
מס' בקשה: 5/602/2016**

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

החל ממועדים אלו קמה עילת התביעה, ודאי כאשר המבקשים מודעים להתנגדות המשיבים ובין הצדדים סכסוך מתמשך (ר' סעיף 30 לבקשה). אין כל הסבר מדוע מאז לא ננקט כל הליך (כמענה לטענה המפורשת בהקשר זה בסעיף 56 לתגובה), ודאי כאשר עסקינן בבניה שבוצעה ללא אישור תכנוני וכאשר מבחינה קניינית כל שיש בידי המבקשים הוא את "העדר טענות" של המשיבים (ר' סעיפים 42 ו-48 לבקשה) ! שיהוי זה, כשלעצמו, מצדיק את דחיית הבקשה.

15. אף אם נקבל את טענת המבקשים כי לאור מדידות שנערכו "הוסכם" על הרחבות דומות בכל דירות הבית, הרי שעילת התביעה הקונקרטית קיימת כבר "מספר חודשים" מאז היו קרובים המבקשים למכירת ביתם, מכירה שסוכלה, לטענתם, לאור דרישות המשיבים נושא הדיון בהליך זה (ר' סעיפים 44-47 לבקשה). גם ממועד זה חל שיהוי אשר מצדיק את דחיית הבקשה.

16. שלישית, גם אין מקום לקבל את הבקשה למתן סעד זמני שעניינה מתן זכות גישה דרך דירת המשיבים לטיפול בקיר החיצוני.

17. בדיון מיום 06.09.16 עלה כי ניתן לבצע את העבודות הנטענות בקירות דירת המבקשים גם באמצעות סנפלינג מגג הבית, מבלי צורך בגישה דרך דירת המשיבים דווקא, וממילא מבלי הקמת פיגומים ופוטנציאל לגרימת נזקים לרכושם של המשיבים (הטעמים להצבת תנאי המשיבים לביצוע העבודות דרך דירתם) (ר' עמוד 2 שורות 2-4).

18. בנסיבות שכאלו, ודאי כאשר מבוקש מתן צו עשה זמני, הרי ששיקולי מאזן הנוחות והיושר נוטים לטובת המשיבים - אף אם ביצוע העבודה באמצעות סנפלינג תייקר את העלות (טענה שלא הוכחה על ידי המבקשים, ולו בראשית ראיה), הרי שקבלת הבקשה משמעה כפיית שימוש ברכוש פרטי של המשיבים לה פוטנציאל גרימת נזק ומטרד. באיזון שבין נזק כלכלי לבין פגיעה קניינית, גוברת זכות הקניין של המשיבים.

19. ויובהר, מתגובת המשיבים עולה כי הם אינם מסרבים לאפשר גישה לביצוע העבודות דרך דירתם. אולם, לשם ביצוע האמור הם התנו תנאים אשר לשיטתם יש בהם להגן על קניינם - התחייבות המבקשים לתיקון כל נזק שייגרם עקב העבודות והצבת שומר כל עוד "עומדים" פיגומים. יוצא, אם כן, כי בידי המבקשים קיימת דרך נוספת (לבד מביצוע העבודה בסנפלינג) לביצוע העבודות כמבוקש תוך שמירה על זכותם הקניינית של המשיבים. המבקשים הם אלו אשר מסרבים לדרך האמורה ובהתאם מאזן הנוחות ושיקולי היושר, ודאי כאשר עסקינן בבקשה לצו עשה זמני, אינם נוטים כלל לטובתם.

20. זאת ועוד. עצם טענת הצורך בביצוע עבודות בקירות החיצוניים לא הוכחה בראשית ראיה כנדרש - לא בחוות דעת מומחה ואפילו לא בפירוט קונקרטי של ביצוע העבודות, לרבות, באמצעות הצעת מחיר, תצהיר קבלן מבצע וכיוצ"ב.

21. רביעית, אומנם, אין בעובדה כי מתן הסעד הזמני המבוקש משמעו הענות לסעד העיקרי המבוקש בתובענה העיקרית, כדי לשלול כשלעצמה מתן סעד זמני כשזו נדרש, אך שיקול זה מצטרף לשיקולים האחרים בנסיבות דנן אשר מטים את כף מאזן הנוחות ושיקולי היושר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 5/587/2016
מס' בקשה: 5/602/2016

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

לכיוון דחיית הבקשה – העובדה כי מבוקש להכשיר חריגת בניה (שבוצעה לפני שנים), העדר ראיה בדבר הבניה המבוקשת או זו שבוצעה, העדר הסכמה בכתב של המשיבים ובעלי זכויות נוספים, קיומה של מחלוקת לאורך שנים בין הצדדים, שיהוי בהגשת הבקשה וקיומן של חלופות רלבנטיות לביצוע העבודות (שממילא לא פורטו כדבעי ולא הוכחו בראשית ראיה) (רע"א 4196/93 שפע בר נ' שפע מסעדות ייצור ושיווק פד"י מז(5) 165).

22. לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה.

23. הוצאות הבקשה בסך של 2,500 ₪ ישולמו בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי וכפי שיקבע במסגרת פסק הדין בהליך.

24. כפי שכבר הוחלט ביום 21.09.16 – כתב הגנה יוגש בתוך 30 יום.

25. דיון בתובענה יערך ביום 07.02.17 שעה 12:30.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום.

ניתנה בלישכתי ביום כ"ב אלול תשע"ו, 25 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין